

的占有状态与管理现状，行为人窃取样态等进行综合判断。通过以上分析，我们可以看出判断是否达到“控制”状态的关键在于行为人对财物是否能够不受阻碍地进行动态的管理或利用。

本案中，三被告人在上游违法行为人将款项转入其提供的银行卡后通过挂失手段截留上游违法行为人部分资金，致使上游违法行为人失去对卡内部分资金的现实支配与控制，被告人方某某作为该银行账户的合法持有人，亦排他性地享有向银行主张卡内资金的权利，其即便不向银行主张，其他人（暂不考虑司法机关介入）亦无法改变卡内资金的归属，方某某似乎实现了对卡内资金的控制，但实际上方某某并未控制并占有卡内资金，三被告人的挂失行为并未达到盗窃既遂的结果，属于盗窃未遂。理由如下：其一，挂失行为导致银行向任何人停止支付的法律后果。挂失虽阻断了上游违法行为人对卡内剩余资金的控制，但同时也排除了三被告人对卡内资金的支配，三被告人在银行卡挂失期间无法进行转账、取现等交易活动，无法毫无障碍地对卡内资金进行现实利用，此时被告人方某某享有的只是一种向银行主张卡内资金的权利即债权请求权。其二，方某某虽享有排他性地向银行主张债权的权利，但该请求权并非等同于对卡内资金实现了支配、控制。即便排他性地享有某项民事权利，也不意味着已经达到了全部目的，在未解除正式挂失之前，方某某仅是处于一种享有权利的状态，民事主体为了实现其利益，还需要作出意思表示，即行为人只有具备一定的条件，能够有效地向银行提出主张债权的要求时，即为支配了该笔银行存款，从而认定其是该项存款的控制人。本案中，方某某等人如要对卡内资金实现现实上的支配、控制，还需方某某通过其本人在银行设置的身份验证并被确认为卡内资金履行的对象，才能享有对卡内资金的支配、控制，方某某只有到银行办理解除挂失手续时才算实现了对卡内资金的支配与控制，达到犯罪既遂状态。而本案三被告人在涉案银行卡挂失期间即被公安人员抓获，尚未办理解除挂失手续，未实现对卡内资金的动态管理与支配，因此属于盗窃未遂。

编写人：山东省济南市市中区人民法院 刘艳青

二、侵犯财产罪

出借银行账户后私自转移被害人汇入钱款的构成盗窃罪

——陈某某帮助信息网络犯罪活动、盗窃罪

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2021)鲁03刑终189号刑事裁定书

2. 案由：帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪

【基本案情】

2020年9月至2021年2月，被告人陈某某在明知熊某某(在逃)利用信息网络实施犯罪的情况下，仍向其提供自己名下微信支付账号及绑定的某1银行账户、林某名下某2银行账户和某3银行账户，为熊某某提供资金支付结算帮助。截至案发，被告人陈某某提供资金支付结算共计22万元。

2021年1月，山东省淄博市张店区居民郭某被他人利用信息网络诈骗64.3万元，其中44万元转入被告人陈某某某1银行账户内，后熊某某转移该银行账户内的15万元。被告人陈某某在熊某某不知情的情况下，办理该银行账户的挂失及补办手续，后将剩余的29万元转移，用于购买车辆、金饰品、手机等。案发后，被告人陈某某退赔被害人郭某违法所得62876.06元。

【案件焦点】

出借银行账户后私自转移被害人汇入的钱款构成何种犯罪，存在构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪或侵占罪、盗窃罪三种不同观点。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市张店区人民法院经审理认为：被告人陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪。被告人陈某某主动退赔部分违法所得，依法酌情从轻处罚。被告人陈某某一人犯二罪，依法应数罪并罚。法院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百六十四条，第六十九条第一款、第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，以帮助信息网络犯罪活动罪判处：

一、被告人陈某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；

二、以盗窃罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元，并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币13000元；

三、扣押在案的微信及支付宝存款30000元予以追缴，退赔被害人郭某；

四、扣押在案的帝豪牌小型轿车一辆、吊坠一个、手串一个、小米手机一部予以变现后退赔被害人郭某；

五、继续追缴被告人陈某某其余违法所得，退赔被害人郭某。

一审宣判后，陈某某提出上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，部分人为谋取非法利益将自己注册的银行账户或手机卡出借或销售给他人，被犯罪分子用于实施电信诈骗、网络赌博、网络贩毒等网络犯罪，这些犯罪所得的钱款通过买卖的银行卡或绑定的微信、支付宝等账户转走，逃避公安机关侦查打击。明知他人实施信息网络犯罪，仍出借、出售银行账户为他人实施犯罪提供支付结算帮助，依法构成帮助信息网络犯罪活动罪。出借、

出售银行账户后又“黑吃黑”，通过挂失、补办、销户等方式将账户内钱款占为己有，更是触犯盗窃罪。

本案中，被告人陈某某将自己的某1银行账户出借给他人使用，后通过挂失、补卡等手段，私自转移被害人汇入的钱款用于个人支出，依法应以盗窃罪定罪处罚。理由分析如下。

第一，被告人陈某某转移私吞钱款的真实目的不是帮助上游犯罪行为人为人掩饰、隐瞒犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪客观上要求行为人实施了窝藏、转移、收购、代为销售等掩饰、隐瞒赃物的行为，其中窝藏、转移行为必须基于本犯（上游犯罪）的意思，即为了本犯的利益帮助掩饰、隐瞒犯罪所得，使司法机关难以发现赃物。本案陈某某转移钱款的真实目的不是掩饰、隐瞒，而是非法占有，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应构成侵财犯罪。

第二，被告人陈某某出借银行账户后即丧失对银行账户及账户内钱款的占有和支配，其与实际银行账户持有人之间也不具有委托保管的合意，难以成立侵占罪。刑法意义上的支配关系是指事实上的支配，而非所有权等法律关系。陈某某将银行账户出借给他人后，已经丧失了对银行账户及其内钱款的占有和支配，即涉案钱款的支配权和所有权均不属于陈某某。侵占罪的行为要件“将代为保管的他人财物”非法占为己有，也即“变合法占有为非法所有”。本案中，银行账户名义持有人王某与实际持有人对于款项没有意思联络，明显缺乏委托意思和保管意思要素，况且陈某某对涉案钱款亦不属于合法占有，故不构成侵占罪。

第三，被告人陈某某转移钱款的行为符合盗窃罪的构成特征。首先，盗窃罪中窃取他人占有的财物，是排除他人对财物的支配状态并建立新的支配关系的行为。被害人的钱款汇入陈某某出借的中国银行账户后，应当认为银行账户实际持有人占有该款项，但陈某某通过挂失、补办新卡的方式，重新建立对银行账户内钱款的控制，系排除实际持有人对银行账户内钱款的支配状态后建立新的支配关系。其次，涉案钱款进账后陈某某即具备转移钱款的条件，采取的

是一种自以为秘密的方式，通过平和手段非法获取他人财物。最后，陈某某明知银行账户中款项并非自己所有，在上游行为人不知情的情况下私自转移使用钱款，违背上游行为人的意志改变钱款占有，主客观相统一，符合盗窃罪的构成要件。

综上，被告人陈某某出借银行卡帮助上游犯罪提供支付结算，并将被害人汇入的钱款私自转移侵吞，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪，依法实行数罪并罚。

编写人：山东省淄博市中级人民法院 赵磊

存款名义人对其名下银行存款占有的判断

—— 史某某盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

陕西省咸阳市中级人民法院(2023)陕04刑终242号刑事裁定书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

被害人高某某于2021年9月从其名下银行账户及其他银行账户将964万元转账至被告人史某某名下的某银行账户内。高某某为使用该银行卡在银行办理业务的便利，2021年9月16日，高某某带史某某一同前往某银行兴平市支行，以史某某的名义重新办理了一张某银行金卡，并将自己的手机号码作为银行预留手机号码。2021年10月6日，高某某和史某某共同前往某银行兴平市支行激活尾号为2606的金卡并办理转账业务，史某某在银行柜台办理激活金卡业务

时，将高某某原预留的手机号码变更为自己的手机号码，并设置了银行卡密码，同时，史某某将其名下尾号为5776的某银行账户内的964万元转入新办理的其名下尾号为2606的某银行卡内。转账成功后，高某某为方便使用并控制卡内资金，持有尾号为2606的某银行金卡，史某某将该卡的密码也告知了高某某。2021年11月6日，高某某将尾号为2606的某银行金卡交给史某某，并告知银行卡密码，让史某某去银行给其银行账户转账200万元，转账完成后，史某某将该银行卡交还高某某；2021年12月14日，高某某持该银行卡在ATM机（自动取款机）取现1000元，并查询卡内余额；2022年1月25日，高某某将该银行卡交给史某某，让史某某给其银行账户（尾号6999）转账140万元用于归还贷款。之后，该银行卡一直由高某某持有，并再未使用过。

2022年2月，被告人史某某因经济拮据，私自将高某某持有使用的尾号为2606某银行卡绑定在自己的微信上。2022年2月28日至6月10日，史某某通过微信充值、扫码支付、刷脸取现等方式，从高某某持有的尾号为2606某银行卡内支出资金848006元。史某某因支取金额太大，遂准备逃跑，6月10日，史某某将高某某持有的该卡在银行挂失，准备补卡后再转走大额资金。6月13日，高某某去银行查询该卡金额时发现卡被挂失，便联系史某某询问情况，史某某见事情败露，随即潜逃。为逃避抓捕，史某某将其逃跑时所开的车辆停放某购物广场门口，乘坐火车到达郑州，在郑州花费16.5万元购买了一辆大众途岳汽车，并办理了虚假的身份证、行驶证、车牌，将原手机卡扔掉，先后逃往湖北、青海等地。其间，借用其朋友赵某某的某1银行卡存放剩余的资金，最后藏匿于某洗浴中心内，直至被抓获。

【案件焦点】

本案被告人行为是构成盗窃罪还是侵占罪。

【法院裁判要旨】

陕西省兴平市人民法院经审理认为：被告人史某某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，被告人史某

某到案后能如实供述其犯罪事实，当庭认罪，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其家属向被害人退赔部分损失，可以酌情从轻处罚。被告人史某某因其犯罪行为给被害人高某某造成的资金损失，应予退赔。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：

一、被告人史某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元；

二、责令被告人史某某向被害人高某某退赔被盗财物损失人民币489089.35元。

一审宣判后，史某某提出上诉。

陕西省咸阳市中级人民法院经审理认为：上诉人(原审被告)史某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪，依法应予惩处。原公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予以支持。原审被告史某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚，其家属已向被害人退赔部分经济损失，依法对其从轻处罚。史某某因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其予以退赔。

关于原审被告史某某及其辩护人所提意见，经查，被害人高某某借用史某某名义办理银行卡存储资金，高某某一直保管该银行卡及密码，并无委托史某某保管、管理、使用该笔资金的意思表示，且按照双方约定，史某某已经自愿交付其对该账户的支配权，被告人史某某不再合法保管、控制该银行卡及卡内资金，史某某在高某某不知情的情况下，通过微信充值、刷脸转账等方式转出卡内资金用于赌博、还债，根据其经济状况并无偿还能力，后因事情败露逃匿外地，足以认定其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了秘密窃取他人财物的行为，其行为完全符合盗窃罪的构成要件，因此该上诉意见及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。

综上，原审判决认定原审被告史某某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、

充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。陕西省咸阳市中级人民法院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

盗窃罪与侵占罪区别的关键在于对占有归属的判断。刑法理论一般认为，刑法中的占有由客观的占有事实与主观的占有意思两个要素组成。然而对于具体情形下占有如何判断，仍然是理论和司法实践中的难题。

一、本案审理中产生两种观点的具体理由

本案审理过程中，第一种观点认为，被告人史某某的行为构成盗窃罪。主要理由如下：被害人高某某借用史某某名义办理银行卡存储资金，高某某一直保管该银行卡及密码，并无委托史某某保管、管理、使用该笔资金的意思表示，且按照双方约定，史某某已经自愿交付其对该账户的支配权，被告人史某某不再合法保管、控制该银行卡及卡内资金，史某某在高某某不知情的情况下，通过微信充值、刷脸转账等方式转出卡内资金用于赌博、还债，根据其经济状况并无偿还能力，后因事情败露逃匿外地，足以认定其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了秘密窃取他人财物的行为，史某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。

第二种观点认为，被告人史某某的行为构成侵占罪。理由如下：首先，被害人高某某将964万元转账存入被告人史某某名下银行卡内，虽然高某某为了方便使用并控制卡内资金而持有该银行卡，但银行卡仅仅只是记载存款人信息等能够使存款人实现存取款项、支配存款的物质载体。我国对银行卡实行实名制，规定必须由本人携带身份证才能申领，银行卡内资金交易的权利和义务由持证申领人享有和承担，即银行卡申领人被视为银行卡的全部权利的所有人，其具有支配、使用卡内全部资金、申请挂失及停止银行卡的使用等各项权利。是故，银行卡无论由谁实际持有并使用，银行卡的权利义务都由申领人承受，卡内资金在法律形式上都处于申领人的控制之下，高某某将964万元存入史某

某名下银行卡的行为，实际上就银行卡内的资金与史某某形成保管关系。因此，借用人高某某虽持有银行卡并掌握银行卡密码，但其一旦将资金存放到借来的卡内，该资金在法律形式上就处于银行卡申领人史某某的控制之下，史某某对银行卡内资金享有合法持有权。史某某虽未持有并保管银行卡，但可通过绑定微信、刷脸转账、挂失后补卡等方式支配卡内资金，对于该卡内的资金具有控制权。根据法律规定，对于自己实际控制的他人财物一般不能成立盗窃罪，只有财物处于他人实际控制下，才有可能以秘密窃取的手段非法占有他人财物而构成盗窃罪。侵占罪的犯罪对象为行为人代为保管的他人财物，行为人在实施侵占行为之前，已经控制他人财物，其特征是将自己控制的财产非法占为己有。控制是指人对财物的支配、管理状态。侵占罪不仅可能侵占自己直接控制的他人财物，而且可能侵占法律形式上控制的他人财物。就本案而言，虽然该银行卡和密码一直由高某某持有，但银行卡内的资金在法律形式上处于史某某的控制之下，史某某完全可以通过绑定微信、扫码消费、刷脸转账、挂失后补卡的方式实际控制卡内资金，对卡内资金行使支配权、控制权。其次，侵占罪作为不转移财物控制权的犯罪，其犯罪故意产生于实际控制他人财物之后，而盗窃罪是转移财物控制权的犯罪，其犯罪故意只能产生于持有、控制他人财物之前。本案中，史某某支取卡内资金的行为发生于资金转账至其银行卡内之后，且卡内资金从法律形式上处于史某某的控制之下，故其行为不能认定为盗窃，而应认定为侵占。最后，被告人史某某明知存入其名下银行卡内的964万元属于高某某所有，仍然私自支取卡内资金，并在挂失补卡事情败露后，逃匿外地，更换联系方式，以此能够证实史某某具有非法占有他人财物的主观故意和拒绝返还财物的客观行为。

二、关于盗窃罪与侵占罪的主要区别

盗窃罪与侵占罪均属于侵犯财产类犯罪，两罪的犯罪对象都是他人的财物，主观上都具有非法占有他人财物的目的，但两罪又有区别，这主要表现在：（1）犯罪的前提不同。侵占罪的行为人在侵占他人财物之前，必须已实际持有或控制他人财物。实际持有或控制他人财物的方式以刑法规定的方式为限，即

代为保管的他人财物、拾得他人的遗忘物和发现他人的埋藏物三种方式。而盗窃罪的行为人在实施盗窃行为前，被盗财物仍处于物主的实际持有或直接控制之下，由于盗窃者的秘密窃取行为才使被盗财物脱离物主的实际持有或控制。

(2) 犯罪目的产生的时间不同。侵占行为人的非法占有目的，发生在实际持有或控制他人的财物之后；而盗窃行为人的不法占有目的，发生在秘密窃取他人财物之前。(3) 犯罪客观方面不同。侵占罪的行为，是对自己已实际持有或控制的他人财物，拒不退还或者拒不交出，从而实现非法占有。手段上既可以是秘密的，也可以是公开的。盗窃罪的行为则是对他人持有和控制的公私财物，采取秘密窃取的方法，使其脱离所有人的控制，从而实现非法占有，其手段只能是秘密的。

侵占罪的法定刑明显轻于盗窃罪，主要有以下原因：(1) 就侵占代为保管的他人财物而言，由于财物已经在其占有之下，相对于侵害他人占有的盗窃罪而言，其仅侵害所有权而不侵害占有权，因而违法性较轻。且处于自己可自由支配状态下的财物对行为人会产生极大的诱惑力，对行为人有责性的评价显然会降低。(2) 无论是侵占代为保管的财物还是侵占遗忘物，被害人均具有一定的过错，使得处罚行为人的必要性降低。

三、对于存款名义人，应从实质上判断其占有权利

结合本案，虽然银行卡的名义人是被告人，并且被告人知道银行卡密码，但是否就意味着被害人委托被告人保管并占有银行卡中的存款呢？若认为只要对于存款具有随时取现的处分可能性，就取得了对于存款的占有，而不追问行为人是否具有正当的取款权限、是否对存款拥有实质性支配的权利，若如此，则盗、骗、拾得他人银行卡并知悉密码后取现的，恐怕也只能成立侵占罪，那么将会导致罪责刑之间的失衡。

具体到本案中，被告人虽然是银行卡的名义人，按照银行法上的世界通例，账号、银行卡及存折仅限于本人使用，但这只是银行法的管理规定，丝毫不能改变账号、银行卡及存折可能被名义人以外的人占有使用的事实。换言之，账号中存款的占有及所有权，到底归属于谁，是需要进行实质判断的。本案中，

被害人只是借用其名下银行卡存储资金，且被害人一直持有并保管该银行卡及密码，被告人史某某明知存入其名下银行卡内的964万元属于被害人所有，先前的取款及转账行为印证被害人对卡内存款拥有实质性权利。被告人之所以取得对卡内存款的支配，是因为被告人是银行卡的名义人，其也知悉银行卡密码，其可通过绑定微信、刷脸转账、挂失后补卡等方式支配卡内资金，但即便被告人具有挂失、补办新卡等权限，也丝毫不能改变其对卡内存款不拥有实质性权利的事实。被害人对涉案银行卡一直自己持有，且案发前两次转账（把卡交给被告人让其到银行操作，转账后被告人将卡交还被害人）一次取现，这都表明，卡内存款不属于刑法意义上的脱离占有物。被害人与被告人之间不存在委托保管关系，卡内存款也不属于委托保管物，被害人以被告人名义办理银行卡，并无将卡内存款转移被告人占有的意思表示，被害人自始至终都对卡内存款拥有实质性权利，且缺乏转移占有的意思与事实，被告人是通过秘密的方式，侵占他人对于存款的占有及所有权，从违法性与有责性来看，也值得定盗窃罪，而不是以法定刑要轻得多的侵占罪论处。

编写人：陕西省咸阳市中级人民法院 刘仲屹 樊志强

单位主要负责人为谋取单位利益 组织实施盗窃行为的定罪量刑

—— 黄某某盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

最高人民法院(2023)最高法刑核69718263号刑事裁定书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

2004年9月，黄某某担任某经济联合社(以下简称联社)的副董事长，2008年6月担任联社党总支部委员会书记，2011年担任联社党总支部委员会书记、董事长，2014年担任联社委员会书记。2006年，在未获得某自来水公司许可的情况下，黄某某安排他人在某外语学院对出路面，将某自来水公司DN600毫米(直径范围)市政供水管擅自开叉驳至DN200毫米水管，向某商务中心供水，并私接一个水表。该水表下设十个分表，分别记录某商务中心各处用水量，联社按用水量向两地用户收取水费，存入联社用水管理中心账户。经审计，自2007年1月至2017年10月，联社因私接自来水管盗用自来水，应向某自来水公司缴纳水费1080341.2元，联社已向某商务中心租户收取水费1369723元。2021年4月，联社向某自来水公司退赔水费1080341.2元。

【案件焦点】

1. 黄某某作为集体经济组织的主要负责人，组织、指使他人盗窃，数额特别巨大，是否构成盗窃罪；2. 本案犯罪行为持续期间有两个司法解释和一个立法解释发布，如何确定适用哪个解释；3. 对黄某某依法应判处十年以上有期徒刑，但本案具有为了单位利益实施盗窃、被盗水费已全部退赔、社会危害程度有所减轻等实际情况，如何量刑。

【法院裁判要旨】

广东省广州市白云区人民法院经审理认为：黄某某盗窃公私财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。据此，以盗窃罪判处黄某某有期徒刑十年，并处罚金1万元。

一审宣判后，黄某某提出上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：原审判决认定事实不清，证据不足，审判程序不合法。据此，裁定：

撤销原判，发回重审。

广东省广州市白云区人民法院经重审认为：黄某某盗窃公私财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。黄某某为联社下属生产社私接水表并盗窃自来水，所窃取的自来水并不是供其个人使用而是联社下属的四个生产社使用；其行为未造成供水市场秩序严重混乱，亦未严重影响广大自来水用户的用水安全；联社在案发后全额退赔了盗取的自来水水费，某自来水公司亦出具谅解书。鉴于本案的特殊情况，决定对黄某某在法定刑以下量刑，据此，以盗窃罪判处黄某某有期徒刑三年，并处罚金1万元。

黄某某提出上诉。广东省广州市中级人民法院经审理，同意一审法院裁判意见。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判，依法报请最高人民法院核准。

广东省高级人民法院经审理，同意一、二审法院裁判意见，同意依法对黄某某在法定刑以下判处刑罚，报最高人民法院核准。

最高人民法院经审理认为：黄某某以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，其行为已构成盗窃罪。黄某某作为集体经济组织的主要负责人，组织、指使他人盗窃，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，鉴于本案实际情况，被盗水费已全部退赔，社会危害程度有所减轻，对黄某某可在法定刑以下判处刑罚。据此，裁定：

核准广东省广州市中级人民法院(2022)粤01刑终460号维持第一审以盗窃罪在法定刑以下判处黄某某有期徒刑三年，并处罚金1万元的刑事裁定。

【法官后语】

本案的争议焦点在于：单位主要负责人为谋取单位利益组织实施盗窃行为的定罪量刑，以及立法解释、司法解释的选择适用问题。

一、单位主要负责人为谋取单位利益组织实施盗窃行为，情节严重的，构成盗窃罪

《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)分则并未规定单位构成盗窃罪。对于单位有关人员为谋取单位利益组织实施盗窃行为且情节严重的，如

何定罪问题，相关立法解释和司法解释的沿革情况如下：2013年发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，单位组织、指使盗窃，符合《刑法》第二百六十四条及本解释有关规定的，以盗窃罪追究组织者、指使者、直接实施者的刑事责任。2014年通过的《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》规定，单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该行为的人依法追究刑事责任。依照上述立法解释和司法解释，对于单位有关人员为谋取单位利益组织实施盗窃行为，情节严重的，直接责任人员构成盗窃罪。本案黄某某的犯罪主观动机是为了为联社及下属的四个生产社经济利益，所窃取自来水不是供其个人使用，而是供四个生产社使用，故黄某某所组织、指使他人实施的盗窃行为是单位行为，因《刑法》没有规定单位构成盗窃罪，应对盗窃行为的主要负责人黄某某以盗窃罪定罪处罚。

二、犯罪行为持续期间有司法解释和立法解释发布，应依法确定适用哪个解释

本案盗窃行为从2007年延续至2017年，上述立法解释和司法解释分别于2013年、2014年发布。2001年12月，《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》规定，司法解释自发布或者规定之日起施行，效力适用于法律的施行期间；对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理；行为时已有相关司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人更有利的，适用新的司法解释；对于在司法解释施行前已办结的案件，按照当时的法律和司法解释，认定事实和适用法律没有错误的，不再变动。根据上述规定的精神，司法解释和立法解释内容一致，效力均适用于刑法施行期间，但立法解释效力高于司法解释，故本案应适用上述立法解释。

